

1500770-79.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... absolvição do crime de associação ao tráfico e em relação ao crime de tráfico pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial brando, a aplicação da detração penal, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decidido.

Afasta-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500770-79.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500770-79.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉRICLES DUARTE MONTEIRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ÉRICLES DUARTE MONTEIRO MAGALHÃES e FÉLIX APARECIDO DOS SANTOS foram denunciados por incursão no caput do art. 33 c.c. art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 18 de abril de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Alfredo Figlia, 504 - Jardim Itapeva, nesta cidade de Mauá, os denunciados, para fins de tráfico, tinham em depósito as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, consoante auto de apreensão de fls. 19-21 e laudo de constatação de fls. 66-9, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que em tempo e local incertos, mas antes do dia 18 de abril de 2022, os denunciados associarem-se entre si e a outras pessoas desconhecidas, com o fim de praticar o crime previsto no caput do art. 33 da Lei 11343/06.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 241 e 318-9) e apresentaram respostas à acusação (fls.232-8 e 244-5).

As testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Por fim, interrogou-se os réus.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa de Félix requer a nulidade da prova produzida e a absolvição. Por sua vez, a Defesa de Éricles busca a absolvição do crime de associação ao tráfico e em relação ao crime de tráfico pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão e do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial brando, a aplicação da detração penal, bem como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Afasta-se a tese preliminar. A denúncia não é inepta, uma vez que atende aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo sido apresentada com base na prova colhida no inquérito policial, de modo que verificada justa causa para a ação penal.

No mérito, procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05-7), auto de exibição e apreensão (fls. 12-3 e 19-21), auto de entrega (fls.17-8), laudo de constatação (fls. 66-9), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 207-9, 210-2, 213-5 e 216-21) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

O réu Éricles, interrogado em solo policial (fl.30), disse que: (sic) "na data de hoje a polícia municipal invadiu a 'casa bomba' da qual o interrogando é responsável e que a casa foi alugada por ele por uma pessoa cujo nome não se recorda. Acerca dos objetos encontrados dentro da casa (roupas e objetos de salão de cabeleireiro e um televisor) desconhece por completo sua origem".

Sob o contraditório, disse que não conhece o réu Félix. Pegou a droga porque passava por necessidade. Era quem cuidava das drogas, há cerca de um mês (mídia digital).

O réu Félix, interrogado na fase administrativa (fl.40), disse que: "estava em companhia de Gabriel nas proximidades do Bairro Itapeva, quando foi abordado por guardas municipais, sendo que nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Alegou que Marcos Wilson Araújo, José Lins Moreira e Éricles Duarte Monteiro são seus vizinhos no Bairro Jardim Iramaia e não soube informar se eles estão envolvidos ou não no roubo praticado no comércio em Ouro Fino, bem como alegou que a casa não lhe pertence e tampouco a droga que foi encontrada pelos guardas municipais".

Em juízo, negou os fatos (mídia digital).

As versões apresentados pelos réus, contraditórias, estão isoladas do conjunto probatório.

O guarda municipal Edmilson historiou que (sic) "durante as diligências realizadas no Jardim Santa Clara na cidade de Ribeirão Pires, os agentes receberam a informação de que o veículo Fiat/Siena de cor azul e de placas ETV 6085 utilizado para a perpetração de roubo num estabelecimento comercial no Bairro Ouro Fino, na mesma cidade e praticado em 13/4/2022, conforme BC0450-1/2022 tinha sido avistado por populares nos bairros de Jardim Iramaia, Pilar e Santa Clara. Diante dessa informação, os policiais municipais passaram a intensificar o patrulhamento, obtendo nova informação de que o referido veículo havia tomado sentido em direção à Avenida Benjamin Batista Cerozolli em direção à cidade de Mauá. Diante dessa nova informação, os patrulheiros solicitaram apoio de outras viaturas da corporação da GCM de Ribeirão e então prosseguiram em direção à Rua Alfredo Friglia, onde finalmente avistaram dois indivíduos saindo do veículo Fiat Siena e ingressando na residência situada no numeral 504 da citada via pública. Contudo, ao avistarem a presença das viaturas da GCM os suspeitos, posteriormente identificado como FÉLIX e um outro não identificado, correram em direção ao quintal e seguidamente passaram por cima dos telhados das demais residências. Nada obstante, o suspeito FÉLIX foi detido em via pública, tendo ele informado ser morador do imóvel de nº 504, ao passo que o outro suspeito conseguiu evadir-se. Como já estavam dentro do imóvel do suspeito, os patrulheiros municipais resolveram ingressar dentro da casa do investigado Félix, onde havia mais três indivíduos posteriormente identificados como Éricles Duarte, José Lins Moreira e Marcos Wilson Araújo Magalhães. Ao serem questionados, José Lins, Éricles e Marcos Wilson informaram que na sala e no quarto da moradia estavam objetos e vestimentas, além de um simulacro de arma de fogo que haviam sido roubados num comércio situado no Bairro de Ouro Fino, na cidade de Ribeirão Pires na data de 13/04/2022. Para além disso, durante as buscas efetuadas dentro da moradia de Félix foi encontrada sob o fogão um piso falso que, uma vez aberto, foram encontradas diversas sacolas plásticas que continham considerável quantidade de drogas prescritas pela legislação regulamentar: 1300 pedras de crack, 842 papелotes de cocaína, 140 frascos do estupefaciente denominado lança-perfume, 149 invólucros plásticos de skank e 176 micropontos do alucinógeno Ecstasy e 780 trouxinhas de substância semelhante à maconha. Ao ser questionado pelo GCM Gomes, o investigado Félix assumiu que se dedica à mercancia ilícita de psicotrópicos, bem como informou que todos os demais presentes em sua casa são comparsas no mundo do crime".

No mesmo sentido o depoimento do guarda civil Gilberto (fls.10-1).

Em juízo, o guarda civil Gilberto afirmou que foi solicitado via rádio por uma equipe de patrulhamento. No local, foi informado que os indivíduos estavam tentando fuga por cima dos telhados, deslocou-se para a rua debaixo e prenderam o acusado Félix. Retornou na residência, onde foram localizados produtos de um roubo praticado em data anterior, bem como entorpecentes. O acusado Félix identificou-se como responsável da residência. Não presenciou quem assumiu a propriedade das drogas. Recebeu informações de que o réu Félix tinha saído da residência e fugido por cima dos telhados, ele saiu no quarteirão debaixo e foi detido, a cerca de 700 metros da residência, a distância de um quarteirão (mídia digital).

Sob o contraditório, o guarda Edmilson disse que receberam informação, via rádio, de que havia um carro transitando com emplacamento envolvido na prática de um roubo. Acompanharam o veículo e viram os indivíduos pulando o muro da residência. Foram detidos quatro indivíduos. O réu Ericles foi detido dentro da residência e o acusado Félix fora, evadiu-se pelo quintal. O acusado Ericles disse que estava na residência com o réu Félix, que era irmão da proprietária da residência. O réu Ericles assumiu a propriedade das drogas, Félix negou, mas estava no local. Depois Félix, em uma de suas versões, assumiu a propriedade das drogas com os demais indivíduos que estavam na residência. Entrou na residência após ver os indivíduos pulando para dentro da casa, porque os indivíduos estavam em fuga. O acusado Ericles e os outros dois indivíduos que estavam na casa, autorizaram a entrada na residência. O réu Ericles foi abordado no quintal da residência. Ericles e os

outros dois indivíduos que estavam no quintal, informaram que todos as coisas ilícitas estavam dentro da residência. O réu Félix foi abordado pela outra equipe, foi perseguido após fugir pelos telhados e abordado em via pública. Não sabe precisar a qual distância da residência. O acusado Félix assumiu a participação nos fatos, após negou (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial, o que também se aplica aos guardas civis municipais. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos guardas municipais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os guardas tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus.

Por outro lado, os réus apresentaram versões inverossímeis e contraditórias.

Descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal de Félix, uma vez que os guardas municipais responsáveis pela abordagem afirmaram que durante perseguição do veículo que teria sido utilizado em crime de roubo, viram o réu e outro indivíduo saindo do referido veículo e ingressando na residência situada no numeral 504, local dos fatos, e que, ao visualizarem as viaturas da GCM, correram em direção ao quintal e passaram por cima dos telhados das demais residências, de forma que justificada as fundadas razões para a busca pessoal.

Também não houve invasão de domicílio.

Houve justa causa para o ingresso dos guardas municipais na casa, visto que, durante acompanhamento de veículo suspeito de ter sido utilizado na prática de um roubo, viram o réu Félix e outro indivíduo saindo do referido veículo e ingressando na residência, mas que ao verem a equipe da guarda civil, tentaram escapar pelo quintal e telhado, sendo que Félix, ao ser preso, disse aos guardas municipais que era morador da residência. Após, encontraram mais de 2kg de drogas na residência onde estava o acusado Ericles e demais indivíduos. Não bastasse, o guarda Edmilson afirmou que o réu Ericles e os outros dois indivíduos que estavam na casa autorizaram o ingresso da equipe na residência.

Cumprе relembrar que o narcotráfico é crime permanente, permitindo-se à autoridade policial, a partir da fundada suspeita, ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, sem mandado judicial ou permissão do morador (Ap. 0000990-27.2014.8.03.0006 -AP, Câmara Única, rel. Carlos Tork, 21.06.2016, v.u.).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS [...] DOMICÍLIO - VIOLAÇÃO - FLAGRANTE - ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, a ocorrência, no momento, de crime, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de autorização judicial. [...] (HC 159017, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019 - grifo nosso).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, porém, conforme se infere do acórdão impugnado do TJGO, após o recebimento de denúncia anônima sobre o intenso tráfico de drogas naquele endereço, os policiais foram em diligência averiguar o caso, e ao chegarem no local "a entrada na casa teria sido autorizada pelos moradores." A versão é a mesma contida no auto de prisão em flagrante, das declarações prestadas pelos agentes públicos. A ação policial logrou êxito na apreensão de 2 porções de maconha pesando 1,055 kg e 3 de crack pesando 0,554, além de uma balança, celular e um veículo Hyundai HB20, vermelho, placa OMT-3218, com restrição de furto e roubo. 4. São válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agravante. Julgados nesse sentido. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 111.760/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2. No julgamento do RE n. 603.616, Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) tratar-se de acusado foragido da justiça em outra ação penal também por delito de tráfico de drogas e previamente reconhecido; II) policiais já estavam em diligência para apurar informações recebidas sobre a comercialização de entorpecentes pelo paciente utilizando determinado veículo; e III) fuga do acusado para dentro de casa após a abordagem policial, tentando escapar pela parte de trás da residência, sendo preso neste momento diante do certo realizado pelos policiais que, após, encontraram mais de 9kg de cocaína na residência. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 615.563/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021 - grifo nosso).

Não bastasse, em recente decisão da Suprema Corte no RE 1.342.077, o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a prescindibilidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais:

"Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE. Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa) [...]."

No mais, a farta quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma de acondicionamento, são elementos suficientes de que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros.

Do mesmo modo, há elementos nos autos que comprovam a associação dos réus para o narcotráfico.

Segundo o apurado, a residência funcionava como "casa bomba", local utilizado, por integrantes de facção criminosa, para guardar grande quantidade de drogas para o abastecimento dos pontos de venda de droga. No imóvel foi encontrado sob o fogão um piso falso com diversas sacolas plásticas que continham enorme quantidade de drogas.

Note-se que o réu Ericles, que foi abordado dentro da residência, em solo policial, afirmou que se tratava de "casa bomba", da qual era o responsável e, em juízo, assumiu a propriedade das drogas, dizendo que cuidava das drogas há um mês, mas tentou isentar o corréu Félix de responsabilidade, dizendo que não o conhecia. Tal versão não é crível, já que os guardas municipais afirmaram que o acusado Félix, que estava entrando na residência e fugiu ao ver a equipe da GCM, assumiu que se dedicava à mercancia ilícita de psicotrópicos, bem como informou que todos os demais presentes em sua casa eram comparsas no mundo do crime. O guarda civil Gilberto afirmou que o acusado Félix identificou-se como responsável da residência. Além disso, o guarda civil Edmilson afirmou que o acusado Ericles disse que estava na residência com o réu Félix, que era irmão da proprietária da residência. Tal cenário indica que os réus estavam envolvidos no narcotráfico, exercendo funções de confiança no abastecimento daquela grande quantidade de entorpecentes. Por óbvio, tal quantidade de entorpecentes não é confiada a pessoas alheias à associação criminosa.

Tudo isso, somado, demonstra que os réus mantinham conduta estável e organizada, apta a indicar a associação para o tráfico.

Tal panorama subsume-se ao suporte fático do artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CARACTERIZADOS OS ELEMENTOS

TIPIFICANTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. [...] 5. Encontra-se suficientemente demonstrada nos autos a prévia combinação de vontades entre, pelo menos, o paciente e uma corré, de caráter duradouro e estável, necessária e suficiente para configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido, em parte." (STF HC 109.708/SP 2ª T. Rel. Min. Teori Zavascki j. 23.06.2015 DJE 03.08.2015).

Ainda:

"É que, a experiência assim está a demonstrar, os criminosos não criam, formalmente, pessoas jurídicas para essa finalidade, não lavram, por óbvio, contratos de associação, a afastar qualquer possibilidade de comprovação documental da reclamada associação. Por outra mão, nem sempre se terá nos autos interceptação telefônica prévia, haja vista que, no mais das vezes, esse tipo de prova só costuma ser produzido, palmar, com a prévia e necessária autorização judicial, quando se está diante de uma associação criminosa para fins narcotraficantes com contornos um pouco mais robustos. No entanto, no dia-a-dia, no comum dos casos, os agentes criminosos associam-se e o fazem em associações que não chegam a ter contornos que chamam a atenção, ao menos em um primeiro momento, das Polícias, Civil ou Militar, mesmo das Guardas Civis. Daí a importância de uma análise meticulosa do que se trouxe aos autos, desde a fase inquisitorial até a fase judicial, a se esperar que, nesta, o obtido anteriormente encontre conforto mínimo a propiciar substrato probatório suficiente para o proferimento de uma sentença condenatória, em 1ª Instância, ou da sua manutenção, em 2ª Instância. E via de regra, está a experiência a revelar que a prova que se encontra à disposição do Magistrado é a de comportas indiciárias, tão maltratada, gratuita e graciosamente, por parte não só da Doutrina, como também da Jurisprudência; como se os indícios não fossem, como são, provas robustas o bastante para sustentar, com folga, a condenação deste ou daquele criminoso enovelado no crime de associação para o narcotráfico." (TJ-SP, Apelação nº 0003469-11.2013.8.26.0451, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Dessa forma, caracterizados os delitos, a condenação é medida de rigor.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, em razão da elevada quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas -780 porções de maconha, 312 porções de cocaína, 1300 porções de crack, 2800 mililitros de lança-perfume, 149 porções de skunk e 176 porções de ecstasy-, fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), fixo a pena-base dos réus em relação ao crime de tráfico de drogas em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Quanto ao potencial lesivo da quantidade de cocaína e crack apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses

menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense – Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 – pg. 180-1).

No tocante ao crime de associação para o tráfico, fixo a pena-base dos réus no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda etapa, em relação ao réu Félix, presente a agravante da reincidência (certidão de fls. 84-5 -proc.0000732-83.2018), as penas sofrem acréscimo de 1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa para o crime de tráfico e 03 anos e 06 mês de reclusão e 816 dias-multa para o crime de associação para o tráfico.

Em relação ao réu Ericles, destaca-se que não basta a confissão parcial, além de não ser espontânea, para a incidência do disposto da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do Código Penal. Além disso, o acusado pretendeu ludibriar o Juízo em relação à associação criminosa com o corréu Félix, apresentando versão inidônea de que não o conhecia.

Sobre o tema:

"É certo que para a obtenção do benefício não se admite a confissão parcial, e o acusado, interrogado em Juízo, negou o emprego de arma de fogo, comprometendo a verdade processual, tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo então o benefício legal. TACRSP: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDTACRIM 31/84)." (TJ/SP, Apelação Criminal 1501289-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data do Julgamento: 06/10/2020, Data de Registro: 06/10/2020 – grifo nosso).

"A confissão parcial não é o suficiente para reconhecer a atenuante porque evidentemente objetivou algum benefício. A confissão espontânea tem que ser plena para valer como tal." (TJ/SP, Apelação nº 0052040-57,2010,8,26,0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Midolla, 02/06/2011).

Na última etapa, não deve incidir a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 já que restou evidenciado que os réus estavam associados para a prática do narcotráfico. Além disso, o réu Félix é reincidente.

Nessa linha, posicionam-se os Tribunais Superiores:

A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes. (STJ, HC 376997 / RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017 – grifo nosso)

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE COM BASE NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. PACIENTE QUE SE DEDICA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi alicerçada em elementos concretos, que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa relacionada ao comércio de drogas. [...] (STF HC 118.380/SP Rel. Min. Teori

Zavascki j. 04.02.14 DJU 14.02.14 - grifo nosso).

"Tráfico de drogas praticado sob a vigência da Lei 6.368/1976. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Paciente que se dedicava à atividade criminosa. Para que a redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 seja concedida, não basta que o agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O voto do eminente Min. Félix Fischer, relator do habeas corpus ora questionado, muito bem explicitou o motivo pelo qual não foi possível a aplicação daquele benefício ao paciente, ressaltando que 'o tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo, a uma, por entender que o paciente se dedicava a atividade criminosa, fazendo do comércio de drogas seu meio de vida, a duas, porque a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 só se aplicaria àquele que como fato isolado vende substância entorpecente, a três, tendo em vista que a sua aplicação é restrita às condenações ocorridas com base na Lei 11.343/2006, não se podendo, assim, a pretexto de se aplicar a lei mais benéfica, combinar partes diversas das duas normas, porquanto isso implicaria, em última análise, na criação de uma terceira lei'." (STF RHC 94.802 Rel. Min. Menezes Direito j. 10.02.09 DJE 20.03.09 - grifo nosso).

Por fim, frente ao concurso material entre os delitos, estabilizam-se as penas em 08 anos e 10 meses reclusão e 1.283 dias-multa para o réu Ericles e 10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão e 1.496 dias-multa para o réu Félix.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica dos réus.

O regime penitenciário inicial será o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a gravidade in concreto dos delitos, notadamente o fato de os réus estarem associados para a prática de crime equiparado a hediondo, a quantidade de droga apreendida, além das nefastas consequências do narcotráfico à sociedade, potencializador da ocorrência de outros delitos, inclusive, tudo isso a indicar um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime mais gravoso mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Pontua-se que Félix é reincidente.

O c. Supremo Tribunal Federal já decidiu da seguinte forma:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA ELEMENTOS CONCRETOS EM DESFAVOR DO RÉU. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO ADEQUADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] V - Na hipótese, não obstante a reprimenda final seja igual a 8 anos de reclusão, é inviável a imposição do regime semiaberto, diante da existência de elementos concretos a figurar em demérito do paciente, a saber, o fato de estar associado a organização criminosa e exercer função específica dentro do grupo, consoante salientado pelo Tribunal a quo. De rigor, pois, a manutenção do regime inicial fechado. vejamos: Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 440.040/RJ, relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem

denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13).

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, insuficientes para prevenção e reprovação da conduta.

Destaca-se ser inviável proceder à detração neste momento, tendo em vista a necessidade da análise de elementos objetivos e subjetivos que somente podem ser aferidos em fase de execução da pena.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu ÉRICLES DUARTE MONTEIRO MAGALHÃES, qualificado nos autos, às penas de 08 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.283 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu FÉLIX APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.496 dias-multa, no unitário mínimo, ambos por incursão no caput do art. 33 c.c. art. 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Defiro aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas apreendidas, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA